

1529122-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "trazer consigo" os entorpecentes.

Já no que toca ao corréu DIOGO, a absolvição integral se impõe.

Conforme relatado pelos próprios policiais, DIOGO apenas estava na viela para onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529122-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529122-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE AUGUSTO MARQUES GERALDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

FELIPE AUGUSTO MARQUES GERALDO e DIOGO MIRLANO DE OLIVEIRA foram denunciados e se veem processados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a Denúncia, "01 de dezembro de 2021, por volta das 23h30min, na Rua Barra do Turvo, nº 148, Mooca, nesta cidade e Comarca, FELIPE AUGUSTO MARQUES GERALDO, qualificado à fl. 23, e DIOGO MIRLANO DE OLIVEIRA,

qualificado à fl. 26, agindo em concurso de agentes, traziam consigo e guardavam, com fins de comercialização, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos transparentes contendo cocaína, 167 (cento e sessenta e sete) invólucros plásticos contendo pedras de crack, 118 (cento e dezoito) invólucros plásticos contendo maconha, 23 (vinte e três) comprimidos contendo Ecstasy, 38 (trinta e oito) recipientes plásticos contendo haxixe, e 35 (trinta e cinco) recipientes vítreos contendo lança-perfume, substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 16/21 e laudo de exame químico toxicológico que será oportunamente juntado aos autos, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 97 (noventa e sete) invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como maconha com massa líquida de 312,3 gramas (trezentos e doze gramas e três decigramas), 27 (vinte e sete) microtubos do tipo "eppendorf" contendo cocaína, com massa líquida de 7g (sete gramas) e 32 (trinta e dois) papелotes com material sólido petrificado contendo cocaína na forma de "crack", com massa líquida de 8,3 gramas (oito gramas e três decigramas), tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 24/27, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.".

Recebida a Denúncia, os acusados foram citados, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogados os acionados.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 14/15.

Laudo de Constatação a fls. 16/21.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 189/192.

Comprovante de depósito judicial do valor apreendido (R\$ 552,00), a fls. 105.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido procede em parte.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls.

14/15, Laudo de Constatação de fls. 16/21 e Laudo Pericial de fls. 189/192, onde se infere que os materiais apreendidos na posse direta de FELIPE, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, cocaína, crack, e maconha.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado FELIPE ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Doutro lado, com relação a DIOGO, a absolvição se impõe, conforme adiante se verificará.

Oportunizado o interrogatório na fase policial, ambos os acionados optaram por permanecer em silêncio (fls. 05 e 06).

Em audiência judicial, FELIPE negou a prática criminosa.

Contudo, apresentou discurso fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, isolado no contexto da prova, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Interrogado, DIOGO negou a prática criminosa.

Doutro lado, temos os relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Lauande Michel Santo Silva e Pedro Henrique Gonçalves, em depoimentos absolutamente consonantes, declararam que participavam de uma operação que visava coibir o tráfico de drogas no local, conhecido pela mercancia de entorpecentes, e, ao se aproximarem, avistaram um indivíduo de moletom amarelo e com uma bolsa pequena preta no pescoço, defronte a uma praça. O sujeito, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, correndo para o interior de uma comunidade, entrando em um corredor. Não obstante, foi acompanhado pela equipe e detido, tendo sido identificado como o acionado FELIPE. Durante

abordagem e revista pessoal, foi localizada expressiva quantidade de entorpecentes no interior da bolsa que trazia consigo, consistentes em 24 invólucros de pó branco, aparentando ser cocaína, 34 pedras envoltas em plástico, aparentando ser crack, 67 trouxas de substância esverdeada, aparentando ser maconha, além de R\$ 70,00 em dinheiro. Indagado, confessou a prática do tráfico, indicando, ainda, que um indivíduo que estava próximo, parado no corredor, identificado, então, como o acionado DIOGO, seria o olheiro. Ato, contínuo, foi efetuada a abordagem em DIOGO, que negou a traficância, mas não soube explicar o que fazia no local. Relatam que foi realizada uma vistoria no corredor em que detidos os acionados, sendo localizada uma mochila de cor azul e, em seu interior, 133 pedras, envoltas em plástico, aparentando ser crack; 51 porções de substância esverdeada, aparentando se maconha; 38 porções de substância que aparentava ser haxixe; 23 comprimidos de ecstasy e 35 frascos com líquido, aparentando ser lança perfume, além de R\$ 482,00. Diante dos fatos, conduziram os suspeitos à presença da autoridade policial. Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado FELIPE trazia consigo considerável quantidade de drogas, consistente em 24 invólucros contendo cocaína, 34 pedras de crack e 67 trouxas de maconha, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente porque o acionado não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Não obstante, é certo que da prova não se consegue extrair o entendimento seguro de que FELIPE era o responsável pelo restante das drogas apreendidas, localizadas em uma mochila que se encontrava escondida na viela onde os réus foram abordados.

Com efeito, muito embora não se coloque dúvidas nas declarações das testemunhas policiais, é certo que, da forma como relatado, impossível vincular a mochila localizada à pessoa do acionado, sendo plenamente possível que esta - e as drogas existentes em seu interior - fossem de propriedade de outrem.

Não há, portanto, elementos sérios que autorizem a conclusão segura de que FELIPE fosse o proprietário ou responsável pelas demais drogas localizadas posteriormente, motivo pelo qual, em relação à conduta de "guardar" tais entorpecentes, a absolvição é medida de rigor, devendo responder, portanto, apenas pelo tráfico dos entorpecentes apreendidos em sua posse direta, na modalidade de "trazer consigo". De todo modo, a grande quantidade de drogas apreendidas, num total de 125 (cento e vinte e cinco) porções de entorpecentes de natureza variada e altamente lesivas, dentre as quais destaco a cocaína e o crack, a forma de armazenamento, guardadas as drogas em porções individuais, prontas para a venda no "varejo", a apreensão de dinheiro em espécie com o acusado (R\$ 70,00 em sua posse direta), as circunstâncias do flagrante, precedida a abordagem pela tentativa de fuga do réu, os depoimentos firmes dos policiais que abordaram o acusado, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável deque FELIPE efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu FELIPE praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória. Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "trazer consigo" os entorpecentes.

Já no que toca ao corréu DIOGO, a absolvição integral se impõe.

Conforme relatado pelos próprios policiais, DIOGO apenas estava na viela para onde FELIPE fugiu, nada de ilícito tendo sido encontrado com ele. Ainda, os policiais não visualizaram DIOGO praticando qualquer ato que pudesse induzir ao entendimento de que estaria ele aliado a FELIPE na traficância.

Ora, neste cenário, tem-se que DIOGO somente foi preso porque, segundo os

policiais, FELIPE teria dito no momento da abordagem que o primeiro exercia a função de olheiro, afirmação esta não reiterada em Juízo pelo segundo, o que informa a prova testemunhal neste ponto, mormente quando DIOGO negou qualquer participação no crime.

Neste contexto, avaliada a prova com responsabilidade, bem de ver que se mostra absolutamente movediça, não dando espaço ao pretendido decreto condenatório em relação a DIOGO.

Portanto, não se pode, com responsabilidade, suficiência e significativa certeza moral, afirmar que DIOGO participou de alguma forma do crime.

Diante de tal quadro, entendendo tímida e precária a prova acusatória, de todo rasa, resumida a mera suspeita, esta que não convence meu íntimo, e, verdadeiramente, me atormenta a convicção, sendo de rigor o pronunciamento do non liquet.

Em situação parelha: É certo que há suspeitas sobre a autoria, mas não um conjunto probatório firme e coeso. Ora, sem que haja uma prova concreta e incontestável, não há sustentação para a condenação. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar a acusação descrita na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Não é caso de absolvê-lo por "estar provado que não concorreu para a infração penal" (art. 386, IV, do CPP) como pretende a defesa, porque, como já dito, há um elemento nos autos que o aponta como autor. O mais adequado, portanto, é o acolhimento do pedido subsidiário, ou seja, a absolvição por "não existir prova suficiente para a condenação" (art. 386, VII, do CPP). Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade". Acerca dessa matéria: "O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP). "Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento unânime" (RJTJESGS 177/136) (Apelação nº 0016929-51.2012.8.26.0564, j. em 24 de agosto de 2015, rel. Desembargador Diniz Fernando).

Portanto, havendo prova precária que corrompa o espírito do julgador, a solução absolutória se mostra como medida de rigor.

Confira-se: Por suas gravíssimas consequências, decreto condenatório não deve ser expedido, exceto se comprovadas, sem falta, a materialidade e a autoria do crime e a culpabilidade do agente. Vêm aqui de molde, pois, estas palavras do eminente Magistrado Hoepfner Dutra: "Na Justiça penal, tudo deve ser certo e preciso como uma equação algébrica. Os elementos probatórios de uma acusação penal devem ser espontâneos, lógicos, consistentes, precisos, harmônicos e, sobretudo, concordantes, para que apresentem em si uma inteireza real a sobrelevar a evidência da verdade. Forçá-los com artifícios é mostrar o intuito de criar uma situação moral grave que, afinal, compromete o resultado da investigação e os objetivos da própria Justiça. Assim sendo, desde que para chegar a uma conclusão a dúvida assalte a consciência de quem julga, o valor de certas provas enfraquece e, por consequência, deve ser preferida a improcedência de uma acusação a um injusto pronunciamento condenatório" (TACRIMSP; Ap. n- 18.186 - São Paulo; j. 30.10.59; v.u.). O princípio geral de que toda a decisão condenatória deve assentar em prova plena e cabal (não só da materialidade do fato criminoso senão também da autoria e culpabilidade do agente) manda afastar da cabeça do réu o gládio da Justiça, nos casos de dúvida invencível. Isto mesmo proclamam nossos Tribunais: "Não basta para a concretização de uma sentença condenatória a simples soma de indícios, por mais veementes que sejam em desfavor do acusado. Ainda mais quando tais indícios foram devidamente contrariados por ampla prova em sentido contrário, restando sérias dúvidas que, em matéria penal, equivalem à ausência de provas (Rev. Tribs., vol.

436, p. 346). Mais que meras conjecturas acerca da culpabilidade do acusado, são necessárias, para sua condenação, provas tão claras como a luz meridiana: "probationes luce meridiana clariores " (cf. Giovanni Brichetti, L 'Evidenza nel Diritto Processuale Penale, 1950, p. 111). Assim, para que o réu não fosse condenado por crime sem prova cabal de autoria e, pois, de culpa, não havia senão pronunciar o "non liquet" e mandá-lo em paz. (Apelação nº 993.03.048470-4, rel. Desembargador Carlos Biasotti).

Bem firmadas as responsabilidades do réu FELIPE, apenas, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis ao acusado, todavia, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes encontrados em seu poder (125 unidade), bem como os tipos altamente lesivos (dentre os quais destaco a cocaína e o crack), nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo suas penas base no cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias multa.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, observo que o acionado é multireincidente, ostentando condenações definitivas pela prática de roubo e furtos conforme se extrai da certidão de fls. 135/139.

Não bastasse, se mostra presente, ainda, a circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (01.12.2021), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta que, necessário consignar é de natureza objetiva, consoante leciona a doutrina: As circunstâncias agravantes genéricas são de caráter pessoal ou subjetivas, quanto: a) ao móbil do injusto ou à finalidade de agir (v.g.: motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem de outro injusto, ou por motivo de lucro); b) a qualidade ou condição pessoal do agente (embriaguez preordenada, com abuso do poder ou abuso de autoridade); c) quanto às relações do autor do ato com o sujeito passivo ou com os outros partícipes (parentesco, relações domésticas, de coabitação, ou hospitalidade; promovendo, organizando a cooperação ou dirigindo a atividade criminosa; instigando, coagindo a execução delitiva). Já as circunstâncias agravantes genéricas são de caráter objetivo, quanto: a) aos meios e modos de execução (traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura); ao tempo e lugar (por ocasião de incêndio, naufrágio, calamidade pública); c) à pessoa ou à condição da vítima (criança, velho, enfermo, pessoa sob estado de desgracia particular, ou pessoa sob imediata proteção da autoridade. (página 405, Direito Penal, Parte Geral, volume 3, 7ª edição, Álvaro Mayrink da Costa); O agente não cria, como na letra d, mas aproveita os efeitos da calamidade pública (além dos exemplos legais: seca, epidemia, guerra, extrema e geral carestia da vida, invasão armada, insurreição, certas greves, etc.) que, por natureza, atinge a coletividade, ou de calamidade particular (acidente, falência, infortúnios domésticos e pessoais em geral, etc.). Em todos os casos, a maior periculosidade define-se pela falta dos requisitos primários da solidariedade humana, pela completa ausência de senso moral. O agente não só desatende a imperativos éticos rudimentares, como não se detém diante dos supremos espetáculos da dor e do perigo, e ainda encontra neles sugestões e estímulos para aumentar a aflição dos aflitos. (página 299, Comentários ao Código Penal, volume 2, 2ª edição, Roberto Lyra); Situações de calamidade pública, como incêndios, inundações, ou mesmo naufrágios, ou de desgracia particular, como acidentes de trânsito, representam condições concretas adversas que reduzem ou excluem a capacidade de proteção pessoal ou patrimonial das vítimas, aumentando a reprovabilidade das ações lesivas de bem jurídicos penalmente protegidos. (página 578, Direito Penal, Parte Geral, 2ª edição, Juarez Cirino dos Santos)

Bem por isso, então, respeitado sempre o entendimento da Defesa, não reclama qualquer nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, máxime porque acerca da edição da norma que decretou o estado de calamidade pública, advinda da autoridade competente a nível Federal e Estadual, não pode o acionado alegar inciência, pena de fazer letra morta do disposto no art.

3º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Assim, frente a tais ponderações, majoro as reprimendas do acusado em 1/4 encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, reprimendas estas que torno definitivas, na medida em que inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas, não sendo aplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06, em se tratando de acusado reincidente.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, no regime inicial fechado, considerando o quantum da pena corporal aplicada, aliado ao fato de que se trata de sentenciado multireincidente, sendo descabido qualquer outro regime mais brando.

Por fim, vale frisar que o acusado praticou o crime em estado de pandemia, conforme salientado na segunda fase da dosimetria, de modo que a gravidade concreta de sua conduta é nítida e merece repressão severa por parte do Poder Judiciário.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada muito acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente que ostenta réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Por fim, a medida sequer seria recomendável (art. 44, inciso III, do CP). Assim, inviável aplicação de pena diversa da corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PARICLAMENTE PROCEDENTE o pedido e assim o faço para ABSOLVER o réu DIOGO MIRLANO DE OLIVEIRA da acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como, por outro lado, para CONDENAR o réu FELIPE AUGUSTO MARQUES GERALDO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu FELIPE, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Quanto a DIOGO, absolvido, expeça-se, incontinenti, alvará de soltura em seu favor. Defiro, ainda, o direito a DIOGO de recorrer em liberdade, caso o pretenda.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu FELIPE lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido (R\$ 552,00 - comprovante a fls. 105) ao FUNAD, posto tratar-se, evidentemente, de produto do tráfico de drogas.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do

Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimadosa.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag

Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06